

1008992-17.2013.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Equilíbrio Financeiro

Magistrado: Marcos de Lima Porta

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 5ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... "tipo A", considerando o volume de tráfico e, portanto, a dificuldade de execução, remunerou-se apenas como "tipo C", de valor mais baixo.

Portanto, cabia à Il. Perita comparar detalhadamente a "realidade de campo", verificada nas visitas realizadas (onde se verificaram todas as vias e o local de execução do contrato), com os serviços apontados nas folhas de campo (ou nas medições ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

5ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-908

1008992-17.2013.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008992-17.2013.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Equilíbrio Financeiro

Requerente:

Consórcio Global Artes

Requerido:

CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Lima Porta

Vistos.

Consórcio Global Artes ajuíza ação cível pelo procedimento comum contra o CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, objetivando o ressarcimento por todos os custos havidos com a falta de segurança, bem como pela execução de serviços extras não remunerados, perda de economia de escala na execução dos serviços em situação diferenciada da originária, bem como despesas indiretas no prazo alongado e alteração de projetos e de especificações como salientado em relatório não contestado.

Alega em síntese que, em 12.11.2008, foi firmado contrato com a requerida para "prestação de serviços de engenharia para manutenção nos sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos, reposição de pavimentos, serviços de troca de hidrômetros, supressão de ligações, execução de ligações avulsas, troca de ligações, assentamento de redes de água e coleta de esgoto do crescimento vegetativo nas áreas dos polos de manutenção de Embu, Capela do Socorro e Campo Limpo - Unidade de Negócio Sul - Diretoria Metropolitana" (fl. 2).

Relata que logo após o início dos trabalhos, situação que perdurou até seu término, o Consórcio se viu diante de vários problemas causados e vinculados, única e exclusivamente, pelo planejamento equivocado e subdimensionado da Sabesp. A desproporção entre o objeto avençado e a realidade encontrada mostrou-se imprevisível e escapava a toda e qualquer programação.

Diz que as citadas alterações eram determinadas pela Sabesp, influenciando de modo unilateral as condições pactuadas, por decisão discricionária ou negligência, mas sempre por sua ação ou omissão, não deixando alternativas a este Consórcio, que não fossem anuir, sob pena de potencial retaliação pela Sabesp, invocando as condições draconianas de seu contrato.

Diz, ainda, que o Contrato em tela experimentou inegável desequilíbrio, pois teve suas frentes de trabalho inviabilizadas e encarecidas pela falta de segurança, ausência de espaço físico para exercer trabalho mecanizado de maior produção, impondo o recurso a serviços manuais, mais lentos e onerosos, como está fartamente documentado, além da ocorrência de serviços extras não remunerados. Quer, pois, a procedência da ação para esse fim.

O requerido foi citado e apresentou contestação. Em preliminar alega falta de interesse de agir pela perda do objeto. No mérito, em síntese, sustenta serem descabidas as alegações feitas e pugna pela improcedência do feito.

Houve réplica.

No saneador, foi afastada a preliminar arguida e determinada a realização de perícia técnica contábil e de engenharia (fls. 886/887).

Juntada do laudo de engenharia às fls. 1240/1387; laudo complementar às fls. 1430/2715; esclarecimentos às fls. 2754/2775, às fls. 2790/2812 e às fls. 2862/2869; e quesitos suplementares às fls. 2813/2837 e 2870/2877.

Parecer do assistente técnico do autor juntado às fls. 2721/2747.

Juntada do laudo contábil às fls. 2953/3000.

Em alegações finais, a autora insiste na reabertura da instrução processual; o requerido reitera sua posição já conhecida.

Esse é o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação em que o autor enseja obter a recomposição da equação econômico-financeira do Contrato firmado com a SABESP com o ressarcimento por todos os custos havidos com a falta de segurança, bem como pela execução de serviços extras não remunerados, perda de economia de escala na execução dos serviços em situação diferenciada da originária, bem como despesas indiretas no prazo alongado e alteração de projetos e de especificações como salientado em relatório não contestado, sob a égide da Lei 8666/93..

O requerido sustenta que "todos os serviços executados pela contratada Global Artes, ora autora, foram contemplados na planilha de preços e evidenciado nas especificações técnicas e regulamentações de preços contidas no referido contrato, não havendo, portanto, nenhuma situação ou serviço não contemplado na planilha contratual" (fl. 550), e, por conta disso, não houve necessidade de aditar preço extra.

O autor insiste na designação de audiência para comparecimento da Il. Perita, com fulcro no § 3º, artigo 477, combinado com o inciso II, do artigo 509, ambos do Código de Processo Civil ("CPC"), em que pese o indeferimento de tal pleito às fls. 2888 (fls. 3018/3021).

Sustenta que o objeto da presente demanda não é o recebimento de serviços extracontratuais, e sim a reclassificação de parte dos serviços que prestou à Ré (que eram medidos e remunerados de forma unitária durante a execução do contrato), tendo em vista que o que foi medido e pago não correspondia ao que foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, a Ré deixou de aplicar, no pagamento de diversos serviços realizados em área confinada e/ou de risco, o preço unitário correspondente à tais situações. O mesmo aconteceu com relação ao pagamento pelo serviço de pavimentação asfáltica, já que em vias onde a remuneração deveria ser a denominada "tipo A", considerando o volume de tráfego e, portanto, a dificuldade de execução, remunerou-se apenas como "tipo C", de valor mais baixo.

Portanto, cabia à Il. Perita comparar detalhadamente a "realidade de campo", verificada nas visitas realizadas (onde se verificaram todas as vias e o local de execução do contrato), com os serviços apontados nas folhas de campo (ou nas medições em posse da Ré, que também poderiam ter sido requeridas).

Pois bem.

Em que pese a insistência do autor em desprestigiar o trabalho pericial, razão não lhe assiste.

Isso porque, a perita judicial de forma clara concluiu que (fls. 1385/1387):

Deste modo, podemos concluir que:

O autor foi contratado pela SABESP e executou a totalidade dos serviços contratados;

O requerente solicitou reequilíbrio contratual em decorrência das alegações constantes dos documentos de fls. 398.469 dos autos, contudo, o mesmo foi indeferido pela SABESP;

A planilha de correção de custos unitários apresentada pelo autor para correção dos valores unitários, não apresentou os critérios para aferição dos valores, nem detalhou os serviços extracontratuais, as obras adicionais ou os serviços em áreas ditas confinadas;

A localização e acessibilidade das regiões contratadas, bem como o crescimento da frota de veículos, possuem informações públicas e de fácil acesso, de modo que o autor poderia acessá-las antes da apresentação da planilha de preços contratuais; Se houve de fato a chamada de forças policiais locais, dentro do tempo de atendimento das autoridades, tal fato poderia ocasionar a inatividade dos funcionários, bem como, o aumento no tempo para o atendimento do serviço, tornando assim difícil a quantificação e mensuração desse custo indireto operacional.

No caso de pedido formal de paralisação dos trabalhos, a variação dos preços decorrentes do acréscimo de prazo contratual a pedido da SABESP é passível de reajuste através de cálculo contábil, uma vez que havia previsão de reajuste na cláusula 4ª do contrato pactuado entre as partes;

Havendo divergência entre a classificação contratual do pavimento e a tipologia encontrada no local, o autor deveria ter cobrado o serviço em conformidade com o efetivamente executado.

Ao final verificamos que a documentação apensada aos autos, em conjunto com as medições apresentadas, diários de obras e relatório de solicitação de reequilíbrio econômico do contrato, não é suficiente para detalhar os critérios para aferição dos valores, nem os serviços em áreas ditas confinadas, dada a extensão das áreas contratadas e das peculiaridades de cada trabalho realizado.

Em quesitos suplementares, a perita judicial assim se manifestou (fls. 1430/1442):

1. Queira a Il. Perita apresentar planilha detalhada, apontando e comparando, via por via, o tipo de material de pavimentação utilizado pelo Autor na execução do contrato com aqueles apontados nas respectivas medições.

Resp.: A relação dos serviços de recomposição de pavimentação efetuados pela autora durante a execução do contrato pactuado entre as partes, encontra-se detalhada em relação à data de execução, localização, quantidade, valor unitário e valor total do serviço executado conforme planilhas fornecidas pela SABESP, juntadas no anexo 1 dos presentes quesitos.

Os valores apontados nas referidas planilhas são compatíveis com as medições dos serviços executados apresentadas pela autora.

Conforme resposta do quesito 7 da autora no laudo pericial, na planilha contratual, os serviços possuíam preços unitários, os quais deveriam ser cobrados em conformidade com o efetivamente executado.

Além disto, havia também a previsão de que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha Orçamento, deveriam ter a sua execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual e seus preços estabelecidos com base no Banco de Preços da SABESP.

Deste modo, entendemos que, se houve a recomposição de pavimento em via com classificação diferente da prevista na planilha contratual, referido trabalho deveria ter sido cobrado em conformidade com o executado.

(...)

12. Com base na visita acima, queira a Il. Perita esclarecer, considerando a natureza urgente e volúvel dos serviços de reparo, se realmente era possível, antes mesmo da apresentação de proposta e assinatura do contrato, o conhecimento de todos os detalhes e aspectos das frentes de serviço.

Resp.: Conforme análise realizada no item 4 do laudo, as áreas delimitadas para os serviços contratados, compreendidas pelo Município de Embu/SP e, pelos Subdistritos de Capela do Socorro e Campo Limpo no Município de São Paulo/SP, constituem regiões periféricas, com ocupação irregular do solo, como invasões, favelas ou assentamentos precários.

No presente caso, a SABESP contrata empresas terceirizadas consecutivamente para execução de serviços semelhantes aos contratados com a autora, de modo que mesmo não sendo possível ter o conhecimento de todos os detalhes e aspectos das frentes de serviços, eventuais dificuldades poderiam ser contempladas quando da composição dos preços unitários da planilha contratual.

13. Informe a Il. Perita, à luz da alegação de que não há provas da necessidade de reforço policial e segurança particular para a execução dos serviços, se, durante sua visita técnica, foi possível adentrar as travessas e vielas mencionadas, transitando pelas áreas onde foram realizados os serviços.

Resp.: No presente caso, foram agendadas 3 (três) novas diligências conjuntas com as partes, nas quais foram realizadas vistoriadas todas as travessas situadas em regiões periféricas mencionadas pela autora, não havendo dificuldade de acesso aos referidos locais, nem a necessidade de auxílio de força policial, conforme detalhado no relatório fotográfico juntado no anexo 4 dos presentes quesitos.

Posteriormente, em razão de laudo divergente apresentado pelo assistente técnico da autora, a perita judicial apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 2754/2775): CRÍTICA: A Perita Judicial, no entanto, não conseguiu valorar o expressivo prejuízo da autora, nem invalidar o cálculo referencial apresentado na inicial, considerando ser o mesmo, atribuição da perícia contábil, a ser ainda realizada.

ANÁLISE: A crítica é improcedente, conforme já respondido nos quesitos suplementares de fls. 1.430/2.715 dos autos, os valores apontados nas referidas planilhas de serviços anexadas são compatíveis com as medições dos serviços executados apresentadas pela autora.

Além disto, eventual compatibilização de valores, item a item como requer a autora, bem como a análise do resultado financeiro trata de matéria de natureza contábil, que foge ao escopo da perícia de engenharia.

Em relação aos cálculos apresentados na inicial, os mesmos são estimativos, cujos prejuízos solicitados não foram devidamente comprovados.

Conforme descrito no item 3.4 do laudo pericial, durante os trabalhos periciais, a signatária solicitou extensa documentação às partes, tendo a empresa autora encaminhado o Livro de Ordem ou Diário de Obras, onde constam informações importantes sobre todas as obras realizadas no período contratual, as quais foram analisadas durante a elaboração do Laudo Pericial. O Diário de Obras totalizou 32 (trinta e duas) caixas de arquivo morto, ou seja, mais de 30.000 (trinta mil páginas), contudo, tais documentos não totalizam todos os serviços executados pela autora durante o contrato pactuado entre as partes.

Em novas reuniões e diligências efetuadas juntamente com as partes, a signatária novamente solicitou à autora a parte restante do diário de obras, contudo, a mesma não juntou aos autos, nem forneceu a referida documentação até a presente dada.

CRÍTICA: Na resposta do quesito 4 da autora, ocorreu um equívoco interpretativo, pois o fato de se conhecer determinada região não significa que conhecer a fundo todos os meandros e recantos da mesma, pois as alterações são dinâmicas, ocorrendo frequentes remanejamentos de trânsito, aumento populacional e de aglomerados urbanos, ou seja, a situação em determinado momento não autoriza a pressupor que será sempre mantida em outro instante. Além disto, pela natureza dos trabalhos, nem a própria Sabesp teria como precisar e discriminar todos os locais onde haveria demanda de serviço, uma vez que a licitação fornece elementos básicos e um descritivo sumário da região que deveria ser atendida, sem o detalhamento integral das referidas áreas.

ANÁLISE: Conforme resposta do quesito 7 da autora no laudo pericial, na planilha contratual, os serviços possuíam preços unitários, os quais deveriam ser cobrados em conformidade com o efetivamente executado.

Havia também a previsão de que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha Orçamento, deveriam ter a sua execução previamente autorizada

por Termo de Alteração Contratual e seus preços estabelecidos com base no Banco de Preços da SABESP. Deste modo, entendemos que, se foram executados serviços diferentes da previsão da planilha contratual, referido trabalho deveria ter sido cobrado em conformidade com o executado.

Além disto, a SABESP contrata empresas terceirizadas consecutivamente para execução de serviços semelhantes aos contratados com a autora, de modo que mesmo não sendo possível ter o conhecimento de todos os detalhes e aspectos das frentes de serviços, eventuais dificuldades poderiam ser contempladas quando da composição dos preços unitários da planilha contratual, não havendo justificativa para o alegado desconhecimento dos locais ou meandros e recantos da região.

CRÍTICA: O laudo judicial, baseado nos informes e informes e detalhes da sistemática executiva imprevista, deveria revisar o posicionamento de que os locais eram previamente conhecidos, reconhecendo ser impraticável, na assinatura do contrato ou na própria licitação e no curso das obras, assumir que se conhecia todos os locais que teriam serviços a realizar por demanda diária e conveniência da Sabesp, pois nem a mesma saberia dizer ou especificar de forma objetiva o que seria preciso fazer em uma semana.

ANÁLISE: No presente caso, realmente foram agendadas 3(três) novas diligências conjuntas com as partes, nas quais foram realizadas vistoriadas todas as travessas situadas em regiões periféricas mencionadas pela autora, devido à extensão dos bairros e vielas a serem vistoriados.

No entanto, não houve dificuldade de acesso aos referidos locais, nem a necessidade de auxílio de força policial, conforme detalhado no relatório fotográfico juntado no anexo 4 dos quesitos suplementares.

Em alguns lugares, realmente haveria a dificuldade de entrar com maquinário para execução de trabalhos, devendo ser empregada mão de obra e ferramentas manuais. Ocorre que, na planilha contratual, os serviços possuíam preços unitários, os quais deveriam ser cobrados em conformidade com o efetivamente executado.

Além disto, havia também a previsão de que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha Orçamento, deveriam ter a sua execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual e seus preços estabelecidos com base no Banco de Preços da SABESP.

Deste modo, entendemos que, se foram executados serviços diferentes da previsão da planilha contratual, referido trabalho deveria ter sido cobrado em conformidade com o executado, de modo que o alegado desconhecimento da região, não justifica acréscimo no valor dos serviços executados.

CRÍTICA: O contrato da Sabesp, não tendo como discriminar os serviços que seriam feitos e atendidos por demanda diária, valeu-se de seu histórico operacional, prevendo uma série de situações, obviamente não exaustivas, e, assim, cada serviço dispôs de sua própria regulamentação de preços (...).

ANÁLISE: Os custos dos serviços estabelecidos nas planilhas de preços da licitação foram baseados em situações hipotéticas, baseadas no histórico de serviços, provavelmente diferente daquelas ilustradas nas fotografias apresentadas pelo autor.

Em se tratando de imóveis situados na periferia, em áreas de ocupação irregular e desordenada, sem acesso à infraestrutura básica, seria possível de se imaginar que tais dificuldades seriam encontradas no decorrer dos trabalhos.

Em tais situações, os referidos custos são realmente mais elevados, contudo, não é possível mensurar quais locais, qual a quantidade de mão de obra empregada, pois parte do diário de obra dos serviços executados, apesar de solicitado, não foi apresentado à signatária ou apensado aos autos.

Uma possibilidade de contornar tal situação, seria pelo fato de o contrato pactuado entre as partes prever que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha Orçamento, deveriam ter a sua execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual e seus preços estabelecidos com base no Banco de Preços da SABESP, ou seja, antes de execução de tais serviços, o autor poderia ter levado os fatos ao conhecimento da concessionária.

CRÍTICA: A resposta pericial em relação aos custos de reposição dos pavimentos é coerente quando aduz que o serviço deveria ser remunerado de acordo com o que foi

de fato executado, pois nada mais justo.

Isto seria coerente e viável não fosse o fato de quem elabora as medições era exclusivamente a Sabesp, sem possibilidade de interferência do Consórcio Autor.

ANÁLISE: Conforme diligências complementares realizadas em conjunto com as partes, as vias identificadas pelo autor já haviam sido recapeadas na referida ocasião, não sendo possível identificar a qualidade tipologia do reparo efetuado nos locais indicados. Deste modo, entendemos que, se a houve a recomposição de pavimento em via com classificação diferente da prevista na planilha contratual, referido trabalho deveria ter sido cobrado em conformidade com o executado.

CRÍTICA: A exemplo dos serviços extracontratuais identificados e levados ao conhecimento da Sabesp, entretanto, retidos pelo seu Gestor, as medições dos serviços de pavimentação eram feitas exclusivamente pela Sabesp.

O Consórcio Autor sempre alertou quanto a esta situação diferenciada de pavimentos, de simples e direta constatação local, mas o Gestor da Sabesp, preocupado em mostrar resultados financeiros positivos, sempre media na condição de menor custo, ou seja, Pavimento tipo C (ruas secundárias).

A situação real é de simples conferência, bastando que a perícia cruzasse as ordens de serviços com os locais onde os trabalhos foram realizados. Isto viabiliza verificar que ali passa tráfego pesado e que não seria viável realizar outro tipo de pavimento leve que não fosse o Tipo A que é o adequado para aguentar e ter maior durabilidade em caso de tráfego intenso e pesado de ônibus.

ANÁLISE: Conforme constou do laudo e das respostas dos quesitos suplementares, na planilha contratual de custos de serviços havia diferenciação dos preços unitários em função do tipo de tráfego da via.

Durante as diligências complementares não foi possível aferir se os reparos realizados pelo autor nas vias indicadas realmente seguiram as especificações para vias de tráfego intenso (tipo A), em virtude de as mesmas terem sido recapeadas, contudo, tais vias apresentavam tráfego intenso que justificaria o reparo do pavimento com preço unitário para o tipo A.

As referidas vias realmente apresentavam características de tráfego diferente do tipo C, contudo, não é possível afirmar se tais serviços foram executados conforme alegado pelo requerente, motivo pelo qual o cruzamento entre as Ordens de Serviço e os locais não é tão simples conforme pretendido pelo requerente.

CRÍTICA: Registrar oficialmente ocorrência policial para acesso aos locais equivaleria a declarar o confronto com as lideranças locais e isto tornaria inviável executar qualquer trabalho posterior na região.

Nestas situações o ritmo de trabalho fica condicionado às permissões dadas e isto se reflete em afetar o desejado equilíbrio contratual que a Perita não conseguiu mensurar. A mera visita da Il. Perita não foi suficiente para que conhecesse a dinâmica e a rotina dessas Comunidades e, portanto, não pode julgar e nem preterir este tipo de pretensão real do Consórcio Autor, que teve que se submeter ao comando da região e trabalhar conforme as suas determinações.

ANÁLISE: As alegações apresentadas pelo requerente são subjetivas e não puderam ser mensuradas por esta signatária, uma vez que não foram encontradas as alegadas dificuldades ou impedimentos, motivo pelo qual, deixamos a decisão a respeito ao E. Critério de V. Exa.

Seguiu-se uma sequência de novos esclarecimentos feitos pela perita judicial, oportunidade em que foram ratificadas suas conclusões anteriores.

Após, foi juntado o laudo pericial contábil, que apresentou a seguinte conclusão (fls. 2953/3000):

Diante do exposto, importante destacar que da análise da Perícia de Engenharia observa-se que não foi determinado critério, parâmetro, autorização, que permita nova apuração relacionada ao tema contábil/financeiro.

Também a Perícia de Engenharia não identificou itens ou valores pagos a menor, motivo pelo qual esta Perícia Financeira não tem elementos para alterar os valores pré-estabelecidos em contrato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, da análise da Perícia de Engenharia, tendo em vista inexistência de novos critérios, parâmetros ou autorização que permita nova apuração relacionada

ao tema contábil/financeiro, esta perícia financeira não tem elementos para alterar ou recompor os valores pré-estabelecidos em contrato.

Nesse contexto, não restou comprovado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nem a alegação da parte autora de que a perita deixou de tratar do objeto da lide.

De rigor, portanto, desacolher o pedido inicial.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, o autor arcará com o pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 5% do valor dado à causa, atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.